

期末复习

关于宪法基础理论

一. 宪法原则

(一) 立宪主义宪法共有：(1) 人权原则 (2004 年宪法修正案)

(2) 人民主权原则 (3) 法治原则 (1999 年宪法修正案提出依法治国) (4) 分权原则 (国外三权分立, 孙中山五权宪法, 我国则是人大制下一府一委两院的相互监督、相互制约, 民主集中制基本原则)

(二) 中国特色：

1. 党的领导原则

(2018 宪法修正案, 第一条) 政治原则+法治原则, 通过宪法规范将党的主张转化为国家意志 (中国共产党是执政党)

政党制度：国外社会团体、政治结社、是基于政治目标, 代表特定政治主张, 代表特定人群的利益

中国共产党政治作为领导核心, 实际上是国家机关--中国政府是广义政府, 包括党组织, 党是国家机关的一部分。三个代表+法国先锋队理论, 说明党不是代表民意而是代表先进——党的领导的正当性基础, 使命性代表而非利益性代表。

党的领导既是政治原则也是法治原则, 通过宪法规范体系(党领导人民制定修改宪法), 通过人大制(民意代表机关的转化), 将党的主张转化为国家意志, -执政地位由历史决定, 执政基础是宪法, 受到宪法约束, 产生法理上的正当性
构建了党的领导—人民当家作主—依法治国三位一体的宪法实施机制 (党的领导有历史基础, 但是更重要的是宪法的确认)

这一原则的实践发展, 既体现于宪法文本的与时俱进 (如 2018 修宪), 更反映在党和国家治理体系的制度创新中

2. 社会主义原则

于西方国体政体 (国家组织形式) 不一样

国家的本质是国家的阶级性质, 中国国体是人民民主专政的社会主义

义国家，是社会主义法治国家。建立在马克思主义国家学说之上，以阶级划分为基础

经济基础:社会主义国家以公有制为经济基础，决定生产关系、分配

关系(按劳分配);资本主义国家按市场分配，不讲什么生产分配关系。

法治核心是坚持党的领导

意识形态，辩证唯物主义、历史唯物主义，社会主义原则核心在于既坚持科学社会主义基本原则，又立足中国实际——马克思主义宪法理论与中国具体实际的深度融合

3.权力制约与监督原则

a.单向监督为主的模式

与西方“三权分立”不同（水平方向的监督，立法司法和行政机关是平级，不是监督而是制约，比如总统立法否决权可以制约立法，司法的宪法审查权也可以制约立法机关），中国实行“议行合一”体制(现

在其实已经不讲这个)，强调**上级对下级、中央对地方的纵向监督**

（中国的大一统观念，一讲到监督就是上对下。但是谁来监督最上级？比如谁来监督全国人大制定的法律？实际上就是假定全国人大制定的法律不会违宪，因为全国人大有宪法解释权，但是这种假定是否正确？违宪审查的制度可能需要突破）。例如，全国人大有权撤销地方性法规，上级监察委领导下级监察委工作。

现在监察委员会也可以水平监督，比如监督同级的政府官员等
监察委员会是**专门的监督机关（中国特有）**

b.党内监督与国家监督的融合

·通过《中国共产党党内监督条例》与国家监察法的衔接,实现党纪监督与监察监督的协同。例如，对党员干部的违纪违法问题，既受党内问责，也受监察机关的调查。（**监察委员会和党内机关二合一**）
监察委员会监督别人，那么谁来监督他们？理论上全国人大可以监督，但是监察委员会又可以监督人大代表个人，实际上非常难以操作。

反腐者自己的腐败成为新的问题。

台湾国民大会可以监督监察机关，但反过来不行。

4.民主集中制原则

少数服从多数，但是也要关注少数人的意见。（中国不太关注）
宪法审查制度本质上反民主——议会的法律是民主制度的产物，宪法审查机关认定其违宪，等于反对民主的产物。违宪审查的关键在于保护少数人的利益，防止多数人的暴政

a.民主集中制是马克思主义政党的根本组织原则和领导制度，也是中国特色社会主义政治制度的核心机制。

b.民主集中制是“民主基础上的集中和集中指导下的民主相结合”的制度，（比如国家机关的权力来源都是全国人大，权力集中于它，然后全国人大又是由民主选出）强调民主与集中的辩证统一。其本质是通过制度化的民主程序形成集体意志，再以集中统一的方式实现决策执行。

（1）民主维度：保障党员和群众参与决策的权利，如党内充分讨论、广泛征求意见等。

（2）集中维度：在民主基础上形成统一意志，确保全党服从中央、令行禁止。**集中体现在国家机构的设置和党的领导与决策上**
民主集中制可以弥补民主决策的效率问题

5.社会主义市场经济

1992 年邓小平南方讲话（体制的弊端，只有最高领导人发话才敢说，依赖领导的英明决策）

1993 年写入宪法，用宪法确认发展成果

二．宪法的制定与修改

1.制宪权：主权的一面，是政治与法律的临界点创设一个国家的法律秩序。宪法可能会过时，所以规定一个制度化的制宪权——修宪权。

中国制定了四部宪法？错误。只有一部宪法，其他都是宪法的修改。如何判断是修改还是新宪法？看宪法原则有没有改变——如党的领导，社会主义原则。75 年宪法和 54 宪法看起来面目全非，但是原则没有变。

2.刚性宪法的修改：议会提出修宪的动议，全体国民进行表决。

中国超过一定比例人大代表提出，全国人大表决通过。

宪法惯例：每次都是中共中央提出建议，全国人大接受，然后提出动议，接着表决通过。每次修宪都是改开到了一定阶段，要对未来发展方向进行一个确认。

3.新中国的宪法制定与修改：见笔记

三．关于基本权利

1.中国宪法基本权利的保护规定了哪些种类？政治经济社会文化的权利，内容非常丰富齐全。要看一看条文

2.中国有哪些没有规定但其他国家规定？——生命权，迁徙自由权（经济自由，劳动力不流通市场就无法运行）司法裁判请求权

54 宪法由后来没有？——迁徙自由（搬的是苏联宪法）计划经济不需要，所以 75 年删去。

75、78 年宪法有 82 年后没有——罢工权

中共最早宪法：中华苏维埃共和国宪法大纲（梁伯台）搬的是 1918 苏联宪法

3.采用什么保护方式？

Ex：美国宪法规定议会不能制定法律剥夺一些基本权利（宪法保留：对该权利进行限制的权力由宪法保留，最为强力的保护方式。这些权利也是**人与生俱来的权利**）

中国都是法律保留：全国人大制定的法律才能限制宪法所规定的权利。

立法法规定：限制人身自由的措施必须法律做出规定。

还有住宅安宁，通信秘密等

但很多没有法律保留，比如结社自由

4.能否直接实施？自由权在一些国家可以。

但是社会权必须立法机关制定法律才能实施。

社会权为什么不能直接实施：因为社会权都是国家为国民提供物质保障社会福利等积极的权利，要财政支持——财政立宪主义，财政问题需要议会制定法律才能决定。

国家与国民的关系——纳税是每个国民的义务，关于财政这样的重大决定只有民意代表机关才能做出。（议会除了立法最重要的就是

财政权——中国人大问题，权力机关却无法限制政府的财政，最近改革后得到强化但还是不够，很多领导退居二线后去人大)

中国所有的**基本权利**都需要立法机关制定法律才能实施

义务也不行——需要法律去落实。宪法中规定的法律义务是公民对

共同体的，只有两个——依法纳税+服兵役。其他基本都是道德义务

(价值宣誓) 比如中国规定的劳动义务，不会强制你去劳动。还有赡养父母，与国家无关，只是倡导一种价值观。

5. 有哪些既是权利也是义务：

劳动 (最多是道德义务，和日本相类似。中国很多法律制度都受日本影响)

受教育：是一个权利 (社会权的一种，国家要积极创造条件为国民提供受教育的机会。也有自由权的面向：可以自由选择受怎样的教育)

义务：义务教育制度

(1) 未成年的父母 (监护人) 的义务，保障他们去接受教育，不是未成年人的义务 (欠缺责任能力)

(2) 国家的义务

五. 平等权：

形式平等：排除不合理的差别对待——排除歧视、特权

比如选拔的时候是否存在歧视：目标和手段之间有无关联性

实质平等：承认合理的差别对待——对弱者的照顾，对强者的限制

比如对失业生活困难者的特步救济

六. 《立法法》

在中国类似于宪法的存在，且得到了很好的实施

1. 立法层级：全国人大制定基本性的法律，全国人大常委会制定基本法律以外的一般法律。由于全国人大会议制度的原因，不能履行太多的立法职能，导致两者界限模糊。全国人大常委会可以对全国人大制定的基本法律进行修改，只要不违背其基本精神。

(1) 法律：立法专属事项有哪些 (只有全国人大才能规定：限制人身自由，政治权利，国家征收私有财产等等)

授权立法：不能授权专属立法事项

(2) 行政法规：国务院制定——是委任立法（立法机关将立法权委托给行政机关行使，因为**立法专业性和效率**需要——政府扩张需要更多法律，议会的立法效率不够）吗？**不是。国务院的立法权不是委托得到而是宪法分配。（中国特色）**

(3) 地方性法规：地方人大——**省级和设区的市的人大制定**，没有立法专属事项。（国外会有，中国只规定下位法不能与上位法抵触）

市级人大有立法范围：《立法法》第八十一条，一共四个（也不是专属立法事项，只是立法权范围的限制。这样的限制没有道理，在实践中也不成功，实际早就超出了范围。但是太多了，所以全国人大也不纠正）

地方为了经济发展需要竞争——已经到了法律的竞争，所以迫切需要相应的立法权，但是立法权又受到立法法限制，所以现在基本都突破了原本的范围。

(4) 行政规章（最低层级的法）：国务院下的各个部门（中央规章）+省和设区的市的人民政府（地方规章）

规章不能创设义务或者削减权利，但现实中也常常突破。

七、备案审查：

公民提出书面审查建议（只是全国人大常委内部的工作规则，还没有专门的制度规定）